محاضرات في
العقود الإدارية

للدكتور/ فؤاد النادي

الفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

إعداد

حازم حكي

كتابة/ عبد الرحمن محمد

مراجعة شكلية/ عمر محمد - حورس

الدفعة 58

خدمة تطوعية غير رسمية

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى"

صدق الله العظيم

إهداء

إلى الدفعة ٥٨ كلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ لقد بذلنا الجهد من أجلكم في سبيل إخراج هذا العمل الذي لا نبتغي به إلا وجه الله تعالى.

شكر وامتنان

مع مرور أربع سنوات منذ أن بدأتُ هذا المشوار التعليمي برفقتكم، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر والامتنان على ما قدمتموه من علم وإرشاد ودعم. لقد كنتم مثالًا للعطاء والتفاني، ليس فقط في التعليم، بل في بناء شخصية طلابكم وإلهامهم للمضي قدمًا نحو الأفضل.

كنتم بالنسبة لي أكثر من مجرد أستاذ، كنتم مرشدًا وداعمًا ألجأ إليه حين احتجت إلى التوجيه، وصوت الحكمة حين شعرت بالتردد. أعتز كثيرًا بكل لحظة تعلمت فيها تحت إشرافكم، وكل نصيحة أضاءت لي الطريق.

أربع سنوات قد مضت، لكن أثر كلماتكم ودروسكم سيبقى معي مدى الحياة. فشكرًا على كل ما بذلتموه، وأسأل الله أن يجزيكم عنّا خير الجزاء، وأن يبارك في علمكم وحياتكم.

مقدمة

بداية وبالله التوفيق، هذا تفريغ لكل ما شرحه الدكتور فؤاد النادي، مع دمجه ببعض التوضيحات اللازمة من الكتاب المقرر، هذا تفريغ العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥

نسأل الله التوفيق لنا ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.

المحتويات

لفصل التمهيدي ٤
أولاً: ما استقر عليه الفقه والقضاء في تعريف العقد الإداري: ٤
ثانياً: تكييف العقد: ٤
ثالثاً: نفاذ العقد من حيث الزمان: ٥
رابعاً: شرط الكتابة: ٥
خامساً: اختصاص القضاء الإداري في الفصل في النزاع: ٦
سادساً: إشكالات التنفيذ في منازعات العقود الإدارية: ٦
سابعاً: لم تشرح. ٦
ثامناً: الوسائل غير القضائية: ٧
عاشراً: النظام القانوني للعقود الإدارية ١٦
لباب الأول إبرام العقد الإداري ١٧
الفصل الأول: المستجدات التي أتى بها القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ..... ١٧
الفصل الثاني القيود التي ترد على حرية الإدارة قبل إبرام العقد الإداري ٢١
القيد الأول: الاعتماد المالي ٢١
القيد الثاني إخطار لجنة تفضيل المنتج المصري ٢٤
القيد الثالث إعداد كراسة الشروط ٢٦
القيد الرابع الإذن بالتعاقد ٢٨
القيد الخامس الاستشارات السابقة ٢٩
القيد السادس التفويض في مجال العقود الإدارية ٣٠
الفصل الثالث طرق التعاقد ٣٣
لمزايدة العامة ٣٥
لغاء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات ٤١
لتعاقد بطريق الاتفاق المباشر ٤٢

الفصل التمهيدي

أولاً: ما استقر عليه الفقه والقضاء في تعريف العقد الإداري:

◦ **تعريف العقد الإداري** :هو العقد الذي يتصل بالإدارة باعتبارها سلطة، وتسعى الإدارة من خلاله إلى تحقيق الصالح العام، سواء كان هذا العقد يتعلق بالتمييز للمرفق أو سريان أو انتهاء المرفق. هو العقد بين الإدارة والمتعاقد.

◦ **العقد الإداري وفقًا للرأي الراجح** :هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام ويقصد منه إنشاء أو إدارة أو إلغاء مرفق، وأن يقصد منه خلاله استخدام وسائل القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في العقد الخاص.

القاضي في العقود الإدارية:

◦ وفقًا للقانون الأخير لتنظيم مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢، القاضي الإداري هو القاضي العام على العقود الإدارية سواءً في إنشاء أو تعديل أو إنهاء.

◦ قانون التحكيم الأول ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يجعل التحكيم هو المسؤول عن العقود الإدارية.

◦ تم الاتفاق على تحديد الاختصاص لمجلس الدولة قبل القانون الأخير لمجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢، حيث حدد اختصاصه على سبيل المثال في المنازعات الإدارية.

◦ هناك من قال بترك العقود للقاضي المدني الذي هو أقدم وأبرع فيها وأكثر خبرة.

ثانياً: تكييف العقد:

◦ يتم النظر إلى العقد لمعرفة ما إذا كان عقدًا مدنيًا أو عقدًا إداريًا لأن الإدارة تملك في العقود أن تستعمل الأسلوبين.

- الإدارة تملك بحسب مصلحتها أن تتعامل كما يتعامل الأفراد أو تستخدم أسلوب العقد الإداري.
- العقد الإداري لا يوجد إلا بوجود ثلاثة شروط:
  - أن تكون الإدارة باعتبارها سلطة.
  - أن يكون العقد يتصل بمرفق عام.
  - أن يكون للإدارة الحق في إنهاء العقد في أي مرحلة من مراحل العقد واستخدام وسائل القانون العام، مثل توقيع الجزاءات.

ثالثاً: نفاذ العقد من حيث الزمان:

- في القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن آرائها الملزمة بالشكل الذي يتطلبه القانون لإحداث أثر قانوني أو المساس بمركز قانوني، والقوانين في القرارات الإدارية تسري بأثر فوري ولا يجوز الرجعية.
- هذا الكلام لا يوجد في العقد الإداري، القانون الذي صدر في ظله العقد هو الذي يسري.

رابعاً: شرط الكتابة:

- في العقد المدني يمكن أن يكون شفهيًا.
- في العقد الإداري شرط الكتابة في العقود الكبيرة.

خامساً: اختصاص القضاء الإداري في الفصل في النزاع:

- **قضاء الإلغاء** :لا يختص فهو ينظر إلى مشروعية تطبيق القاعدة القانونية: السبب، المحل، الشكل، الاختصاص، الغاية. ولا يتغلغل في مركز الخصومة.

- **قضاء الكامل** :هو الذي لا يقف عند حد المشروعية وإنما يتغلغل في مركز الخصومة ويزيل كافة الأثر على العيب الذي لحق القرار الإداري، ولكنه لا يختص بكل النزاعات لأن هناك قرارات إدارية منفصلة عن العقد الإداري.

سادساً: إشكالات التنفيذ في منازعات العقود الإدارية:

- هل هي في قانون المرافعات والقضاء المستعجل أم في القضاء الإداري؟

- **قضاء الإلغاء** :إذا كان متعلقًا بقرار إداري فهو يتوقف عند حد المشروعية ولا يتغلغل.

- **قضاء الكامل** :يتغلغل في مركز الخصومة وينظر إذا كان هناك عيب في الشكل.

- **حكم القاضي المستعجل** :يتخذ إجراء عارض فلا يتغلغل في العقد. إذا حكم في الموضوع من موضوعات الحكم، فهذا يكون باطلًا لأن القضاء المستعجل يقف عند مسألة تحفظ إلى أن يبت في النزاع. فهو لا يتعرض للموضوع بل يتعرض لأمر عارض لوجود عيب من العيوب وقصر في سلامة القرار الإداري. مثل؛ شخص يبيع مالًا عامًا، هذا المال الوزارة نفسها لا تقدر على بيعه ولكن تستطيع الإدارة الحكومية فيه ومملوك للدولة ملكية خاصة، ولكن لا تستطيع جامعة الأزهر بيع كلية الشريعة والقانون. ولو جلبوا فلوس للأرض تشتري الحاجة برخيص وتبيعها غاليًا، ولكن المال العام لا يقبل التصرف والاستعمال والاستغلال.

سابعاً: لم تشرح.

ثامناً: الوسائل غير القضائية:

- حينما صدر قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من ٧٢ إلى ٩٤ الفقه ينقسم إلى قسمين:

١. في قانون التحكيم سنة ٩٤ أن تستخدم التحكيم بشرط أن العقد يتصل بمرفق والوزير المختص هو الذي يأذن وأعطوا قيمة محددة. لأن مجلس الدولة في قسمين: إدارة الفتوى ولجان الفتوى. فإدارة الفتوى الأزهر والشئون الاجتماعية والأوقاف لهم إدارة كلهم مع بعض بدرجة وكيل وزارة. معقول أن الوزير المختص يرأس شيخ الأزهر إلى أن تعدل القانون وأصبح شيخ الأزهر بدرجة وزير وبعد ذلك تعدل وأصبح بدرجة رئيس وزارة. فأصبح شيخ الأزهر في حكم رئيس وزارة، فأصبح أي وزير لا يستطيع أن يرأس شيخ الأزهر. ولذلك في قانون الأزهر عدل وجعل المشيخة هي السلطة المركزية.

- ما هي علاقة السلطة المركزية باللامركزية؟ جامعة الأزهر شخص من أشخاص اللامركزية الإقليمية، يعني شخص مستقل عن شيخ الأزهر، ولكن شيخ الأزهر يعتبر سلطة مركزية له:

١. الرقابة.

٢. سلطة التوجيه، بمعنى يوافق على القرار كله أو يرفضه كله. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يحل محل الشخص الاعتباري، وإنما لابد وأن ينزل ويترك الأمر لمجلس الجامعة ويبلغ شيخ الأزهر بالقرار خلال ٨ أيام، لأن شيخ الأزهر له أجهزة قانونية. فإذا رأى شيخ الأزهر أن هناك عيبًا فيقوم بإرجاعه ثانية، ولا يحل محله لأن السلطة المركزية ليس لها تعديل أو تأمر أو تنهي على نحو معين. ولكن دوره فقط أن القانون يقول إنه عندما يخرج الشخص

اللامركزي عن حدود السلطة المحددة فيقبلها كلها أو يرفضها كلها. فإذا لم يعدل وأصر على موقفه، فالحل هو القضاء.

- هذه هي فكرة أن الوزير يأذن بالرجوع للتحكيم. في ٩٤ قال يمكن أن نلجأ إلى وسائل غير قضائية:

١. بشرط يتفق الطرفان على ذلك الإدارة والمتعاقد معها.

٢. والشرط أن يكون من الوزير المختص مثل الوزير شيخ الأزهر.

٢. يمكن أن نلجأ إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع في العقود التي تكون بين جهتين أو أكثر، وهذا كان يطبق من بين ٧٢ حتى ٩٤.

- <u>من الاتجاهين إلى من نلجأ:</u>

١. القانون الخاص والمحاكم الخاصة.

٢. أن يوفق الوزير المختص ولا يكون متعلقًا بالنظام العام.

- سنة ٧٢ نصت الفقرة ١٤ أن مجلس الدولة مختص بسائر المنازعات الإدارية. حتى ٩٤ كان هناك لغط أنه يمكن أن نلجأ إلى وسائل القانون الخاص. لا، لأن مجلس الدولة من ٧٢ هو صاحب الولاية على المنازعات الإدارية. لذلك البعض يرى أن المنازعات التي تقع في المستقبل إذا كان الأمر يتعلق بتغلغل في مركز الخصومة. البائع والمشتري أنه الأحسن نديهم القانون الخاص لأنه أكثر خبرة. حتى أتيت المادة ٤٧ لسنة ٧٢، وحسمت أن مجلس الدولة يختص بسائر المنازعات الإدارية. وجاء قانون التحكيم وقال يمكن اللجوء إلى الوسائل الودية لإنهاء النزاعات الإدارية وفي سريان العقد بشرط أيضًا أن يحل إلى القضاء المختص

إذا اتصل بالنظام العام. لأن كل ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته. حتى طلع قانون ٨٩ لسنة ٩٨، وحسم المسألة وهو قانون المزايدات والمناقصات. أنه يجوز تضمن العقد الإداري بشرط أن يكون ورد في العقد وأن يكون من موافقة الوزير المختص. المادة ٤٢ الأخيرة لقانون المزايدات والمناقصات حسمت المسألة أنه إذا نص التحكيم الإداري في العقد، وأنه يمكن أن يشمل ذلك قضاء التعويض.

هل يجوز للإدارة أن تستخدم الوسائل غير القضائية في تسوية المشاكل التي تعتري العقد أثناء إنشاء أو تعديل أو إنهاء وهي وسائل غير تقليدية:

١. التوفيق.

٢. الوساطة.

٣. التحكيم.

٤. اللجوء إلى قاضي الإلغاء في القرارات المنفصلة.

١. **التوفيق** :هو صورة من صور محاولة إنهاء النزاع صلحًا. ويجب أن يتضمن العقد شرط التوفيق، ولكن رأي الموفق غير ملزم. ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا لم يقبل الطرفين أو أحدهما ما حكم به الموفق، واللجوء إلى التحكيم بشرطين:

أ-أن يكون العقد يجوز ذلك.

ب- موافقة السلطة المختصة.

٢. **الوساطة** :هي نفس نظام التوفيق، وهو أن يختار طرفين شخصًا ثالثًا حتى يحل النزاع بينهم. ورأيه غير ملزم للطرفين، فهو يحل محل الموضوع بخبرته في النزاع. ويجب ألا تكون المنازعة متعلقة بالنظام العام لأنه لا يجوز الصلح.

٣. **التحكيم** :هو من أهم الوسائل غير القضائية التي يجوز اللجوء إليها لحل النزاع بين المتعاقدين. أهمية التحكيم تكمن في طبيعته الرضائية، فضلًا عن السرعة في حل النزاع وسرية الإجراءات، وتمكن أطرافه من الحفاظ على أسرارهم ويحتفظ بالعلاقات التجارية. ويؤدي إلى تخفيف العبء على القضاء، ولكنه يتميز بأنه يكون ملزمًا بخلاف الوسائل غير القضائية الأخرى. كما أنه أكثر تنظيمًا وتشريعًا.

٤. **اللجوء إلى قاضي الإلغاء في القرارات المنفصلة** :اللجوء إلى قاضي الإلغاء يُعتبر وسيلة قانونية تُستخدم للطعن في قرارات السلطة الإدارية، وذلك لضمان احترام الشرعية والقانون في أداء السلطة الإدارية لمهامها. ومع ذلك، هناك وسائل غير قضائية يمكن اللجوء إليها قبل التفكير في رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري. هذه الوسائل غير القضائية تهدف إلى حل النزاعات أو تسوية الموقف دون تدخل المحاكم، خاصةً في الحالات التي يكون فيها الحل التفاوضي أو الإداري أكثر فاعلية.

تاسعاً: اختصاص الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع

تُعد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جزءاً من مجلس الدولة، وقد حدد المشرع اختصاصات محددة تتعلق بالعقود للجمعية العمومية.

قسم الرأي

يتألف قسم الرأي من قسمين:

- **لجان الرأي**
- **وزارات الرأي**

تشمل وزارات مثل وزارة المالية ووزارة التخطيط، ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

يتم تشكيل قسم الرأي لتقديم الآراء القانونية، وفي ذات الوقت، يرسل مجلس الدولة مفوض الدولة إلى الجهة الإدارية ذاتها لتقديم الرأي في العقود التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه.

- **قسم الرأي** :يقدم الرأي في العقود التي تقل قيمتها عن ٥ آلاف جنيه.
- **قسم الفتوى** :يقدم الرأي في العقود التي تتراوح قيمتها بين ٥ آلاف و٥٠ ألف جنيه.
- **الجمعية العمومية** :تقدم الرأي في العقود التي تزيد قيمتها عن ٥٠ ألف جنيه.

إدارة الفتوى

لدينا ٥٠ وزارة، ولكل وزارة إدارة. في حال وجود وزارتين متشابهتين، يتم تشكيل إدارة واحدة، مثل وزارة التعليم والتعليم العالي. إذا رأت الإدارة رأياً يخالف رأي إدارة أخرى أو رأت رأياً جديداً، تُرسله للجمعية العمومية عبر اللجنة.

الإجراءات المتبعة

في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ٥٠ ألف جنيه، تُعرض على الجمعية العمومية. إذا حصلت الإدارة على رأي جديد، تُرسله للجنة، وإذا رأت اللجنة أن المسألة تحتاج للجمعية العمومية، تُرسله إليها.

المبادئ العامة التي تتبعها الجمعية العمومية

أ. **العقود الإدارية** :تكون جميع العقود الإدارية من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مما يعني انحسار دور القانون المدني والمحاكم المدنية في هذا الشأن.

ب. الأطراف المتعاقدة من القانون الخاص :إذا كان الطرف المتعاقد مع الإدارة فرداً من أفراد القانون الخاص، فلا تكون الجمعية العمومية مختصة، حيث تقتصر اختصاصاتها على التنازع بين جهتين إداريتين من القانون العام، وتصدر في هذا الإطار فتاوى نافذة.

ج. المنازعات والأحكام من الجهات غير المختصة :إذا صدرت منازعة حكم من جهة غير مختصة، بمعنى أنه لا ولاية لها، في هذه الحالة لا يُستأنف أمام المحكمة الإدارية العليا، بل يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

د. اللجوء إلى لجان التوفيق :لا يجوز رفع أي قضية على الحكومة إلا بعد اللجوء إلى لجان التوفيق.

كيف نشأت لجان التوفيق؟

كانت هناك لجان إدارية منذ سنة ١٩٥٢ بموجب قانون مجلس الدولة، للتخفيف عن المحكمة الوحيدة في مصر ومقرها القاهرة. أُلغيت هذه اللجان في القانون الأخير لمجلس الدولة وصدر قانون التوفيق، مما يعني أنه لا يمكن رفع دعوى تعويض أو دعوى إلغاء إلا بعد اللجوء إلى لجان التوفيق .إذا كان الأمر يتعلق برأي من إدارة الفتوى، لا يمكن الذهاب إلى لجان التوفيق لأن الهدف منها هو تخفيف العبء عن مجلس الدولة. وإذا كانت المنازعة تتعلق بالعقود الإدارية، يمتنع على الجهة الإدارية أن ترسل إلى لجان التوفيق.

هـ. عدم جواز إعادة النظر في الرأي الملزم :إذا بُتّ الأمر برأي ملزم، لا يمكن إعادة النظر من الجهة الإدارية أو الشخص المتعاقد مع الإدارة. رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع يعتبر نافذاً في النزاع بين جهتين إداريتين. رغم أن رأي الجمعية استشاري، إلا أنه إذا كان النزاع بين جهتين إداريتين، فهو يكون نافذاً.

و. **الدفع بالتقادم** :التقادم يكون ثلاثياً أو خماسياً أو لمدة ١٥ سنة. في النزاع بين جهتين إداريتين، ليس هناك مهزوم أو كاسب لأن جهات الإدارة واحدة يرأسها رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني. لذلك، الدفع بالتقادم لا يجوز، مثلما حدث مع جامعة الأزهر بعد القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ عندما أخذوا معهدًا في أسيوط لجامعة الأزهر. بعد ١٥ سنة، لا يمكن لجامعة الأزهر أن تدعي بوضع يد التقادم لأن كلها إدارات تبع الإدارة والمصاريف تابعة لموازنة الدولة.

ز. **عبء الإثبات بين جهتين إداريتين** :يقع عبء الإثبات على الجهة المدعية.

الطبيعة القانونية للرأي والفتوى

سواء كنا أمام قسم الرأي أو قسم الفتوى أو الجمعية العمومية، كل ما تصدره لا يُعتبر حكماً أو قراراً إدارياً، بل يُعتبر فتوى نافذة أمام الجهات الإدارية. الحكمة من ذلك هي عدم نشر "الغسيل الوسخ" أمام الناس. لا يجوز لمشيخة الأزهر وجامعة الأزهر اللجوء إلى المحاكم. هذا الرأي يخضع لإجراءات بطلان لأنه مجرد رأي، حتى ولو كان نافذاً في حق الإدارة.

التطبيقات

١- التمويل:

- **عدم وجود الدعم المالي** :إذا صدر قرار إداري بإعلان عن وظائف والميزانية لا تحتوي على الأموال، يكون الإعلان باطلاً والتعيين باطلاً لأنه ليس له سند مالي. هذا البطلان لا يتحصن في العقود بين جهة الإدارة والمتعاقد معها. مثلاً، إذا أرادت جامعة الأزهر إقامة كلية

في شبرا ولا يوجد دعم مالي، فلا يجوز للإدارة أن تدعي بطلان العقد حتى ولو لم يكن هناك دعم مالي. إذا أُبرم العقد، يحق للمتعاقد رفع دعوى على الإدارة ووزير المالية.

٢- **الكتابة** :الكتابة شرط في العقد الإداري. في العقود قليلة الأهمية؛ مثل توريد أغذية في المدينة الجامعية، إذا لم يصل الملح يجوز التعاقد على الملح بدون كتابة العقد. قالت الجمعية العمومية إنه في بعض العقود قليلة الأهمية لا يشترط كتابة العقد.

٣- **فسخ العقد والأثر المترتب عليه:**

. **الفسخ في المدني والتجاري** :رغم وجود شرط الفسخ في العقد أنه ينفسخ من تلقاء نفسه أو إذا اختلف أحد المتعاقدين، لا يتم تنفيذ الشرط بل يتم اللجوء إلى القضاء.

. **أمر يتعلق بمنازعة الإدارة** :القرار الصادر من الجمعية العمومية بالفسخ يمكن تنفيذه دون اللجوء إلى القضاء.

٤- **الاتفاق المباشر** :بين الجهات الإدارية والشخص، قانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ جاء بإجراءات صعبة. قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ خفف من هذه الإجراءات وقال إن الإدارة ليست ملزمة بإجراءات عديدة وكثيرة تتعين في الاتفاق المباشر. ورغم ذلك، الاتفاق المباشر فيه شبه لإن من يبرم التعاقد هو بشر ويعتبر الاتفاق المباشر من عيوب القانون الجديد.

٥- **ما يتعلق بالعقود الإدارية والتحفظات** :عند عمل عقد، يتم ذكر الشروط مثل عدم رفع شيء معين أو القيام بعمل في وقت معين. هذه التحفظات قيد في العقد. إذا لم يتم الالتزام بالتحفظات، يتم فسخ العقد.

٦- **إسناد الأعمال المستجدة** :وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات، يأخذ المقاول بسعر السوق للأعمال المستجدة. إذا كانت الأعمال مرتبطة بسعر الدولار وحدثت زيادة في الأسعار، يمكن طلب الزيادة بشرط عدم التأخر عن التسليم.

عمل الأمير

ظهر عمل الأمير في فرنسا عندما كانت دولة ملكية، حيث كان الملك يصدر قرارات ملزمة للجميع، بما في ذلك المتعاقدين. عمل الأمير يتدخل لإنقاذ المتعاقد مع الدولة في حال حدوث طارئ غير متوقع. فإذا لم تتدخل الدولة، يتوجه المتعاقد إلى المحكمة. مثال على ذلك، عقد توريد آلات ارتفع سعرها فجأة، عمل الأمير يتناول أمورًا غير متوقعة أو غير قابلة للتوقع.

١. ما يكون متوقعًا:

- زيادة أسعار النقل بسبب الحروب العالمية يمكن توقعه فلا يتدخل فيه عمل الأمير.

٢. ما لا يكون في الوسع توقعه:

- أن الخبراء يعلمون بحدوث حرب مستقبلية، وتعتمد هذه الأمور على الخبرة. وتكون في العقود الإدارية حيث يتدخل عمل الأمير ويزيد الأسعار.

٧- **تصحيح الأخطاء المادية** :الخطأ المادي في القرار الإداري مثل بيع بيت وعدم معرفة حدوده بدقة. الجمعية العمومية استقرت على أن الأخطاء المادية يمكن تصحيحها في العقود الإدارية ولا يبطل العقد.

٨- **أعمال شرط فروق الأسعار** :عند توريد شيء وزيادة سعره، يجب زيادة قيمة العقد أيضًا.

تسوية المنازعات عن طريق الجمعية العمومية

إذا كان النزاع بين جهتين إداريتين، الأصل أنه لا يجوز اللجوء للقضاء، بل يحل النزاع في الجمعية العمومية. مثال: جامعة القاهرة لديها أكبر ورشة أثاث في مصر بكلية الزراعة وتعمل لأي جهة إدارية. إذا حصل نزاع بينها وبين جهة أخرى، لا يلجؤون للمحاكم لأنها من السلطة الإدارية. الجمعية العمومية تتولى تسوية المنازعات المتعلقة بالعقود، ويمكنها شطب اسم المقاول بسبب

عاشراً: النظام القانوني للعقود الإدارية

العقد الإداري عقد مركب يحتوي على عنصرين:

١. عنصر إرادي.

٢. عنصر لائحي.

العقود الإدارية كلها مركبة تحتوي على قواعد:

١. قواعد عقدية من القانون الخاص.

٢. شروط غير مألوفة.

٣. استخدام وسائل القانون العام.

الباب الأول

إبرام العقد الإداري

الفصل الأول: المستجدات التي أتى بها القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ هو الشريعة العامة للعقود الإدارية في مصر، وقد أتى بمستجدات لم تكن موجودة في العقود الإدارية السابقة، وركز على تحديد الهدف من التعاقد الإداري.

١. **تحديد الأهداف:**

أ. تنظيم إجراءات التعاقد ورسم تخطيط وتنفيذ التعاقدات الإدارية.

ب. كفاءة وفاعلية التعاقدات.

ت. حرية التعاقد ومنح المساواة بين المتنافسين.

ث. استخدام أساليب حديثة في التعاقد.

ج.تطوير طرق البيع والشراء.

ح.ترسيخ المعاملة العادلة مع مجتمع الأعمال.

خ.تشجيع المبادرات الابتكارية.

د. إيجاد مناخ للشركات المتوسطة والصغيرة.

ذ. ضمان الشفافية في جميع الممارسات.

٢. توسيع دائرة اختصاص القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨:

- القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تميز بإدخال أمور جديدة للعقد الإداري، مثل الصناديق الخاصة والمعاشات والموازنة العامة للدولة والهيئة العامة للتصنيع والإنتاج الحربي، وأجاز التعاقد لهذه الجهات عن طريق التعاقد المباشر. كانت الصناديق الخاصة والموازنة العامة للدولة والإنتاج الحربي خارج اختصاص العقود الإدارية، وأدخلها القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وأجاز التعاقد لهذه الجهات عن طريق التعاقد المباشر.

٣. وجوب إنشاء إدارة للتعاقدات في كل جهة إدارية:

- تختص بالتعاقدات الحكومية التي تجريها الإدارة من احتياجاتها السنوية، ومتابعة تنفيذ العقود، والتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية.

٤. مكافحة الفساد:

- ألزم القانون الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإمساك سجل لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع الجهات الإدارية، بما في ذلك القضاء وأعضاء مجلس النواب والمحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحتالين.

٥. تطبيق الأساليب الحديثة:

- أوجب القانون ١٨٢ استخدام طرق حديثة في التعاقد، مثل النشر عن العمليات على بوابة التعاقدات المصرية، بدلاً من الطرق القديمة التي كانت تقتصر على النشر في صحيفة أو صحيفتين.

٦. **في مجال تحفيز كبر عدد من المتنافسين:**

- بالنسبة للعطاءات التي تزيد مدتها عن ٦ أشهر أو أكثر، مثل عقود المقاولات، ألزم القانون جهة الإدارة بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقصان في بنود العقد.

٧. **ترشيد الاتفاق العام للوحدات:**

- أجاز التعاقد على استئجار المنقولات في القانون الجديد، بينما كان القانون القديم يقتصر على استئجار العقارات فقط.

٨. **التعاقد من الباطن:**

- كان القانون القديم (قانون المناقصات والمزايدات ٩٨) يشترط شروطًا للتعاقد من الباطن:
  - أن يكون مع شخص ذو خبرة.
  - أن يكون الشخص ذو رأس مال.
- أما القانون الجديد ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، فقد أجاز التعاقد من الباطن بشرط:
  - ألا يكون من الأشخاص الممنوعين من التعامل.
  - ولا يشترط فيه شروط التعاقد في العقود الإدارية.

٩. **تفويض الاختصاصات:**

- التفويض يخفف من عبء السلطة المركزية.
  - في قانون المناقصات والمزايدات ٩٨، كان لا يجوز التفويض في بعض الأمور التي حددها القانون أنها من اختصاص جهة معينة.

- في قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، يجوز لصاحب الاختصاص التفويض في اعتماد القرارات، ويكون الحد الأدنى للأشخاص الذين لهم التفويض هو مدير عام.

١٠. المنتجات المصرية في العقود الحكومية:

- إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة ١٥٪ من قيمة أقل عطاء أجنبي، يتم تفضيل المنتج المصري.
- إذا كانت الزيادة عن ١٥٪، يمكن الترسية على المنتج المصري ولكن بشروط معينة.

١١. التوسع في التعاقد المباشر:

- التعاقد بطريقة المباشر هي تجوز كل الشروط التي تتبعها الإدارة في التعاقد، وهذا يكون في الحالات العاجلة بسبب أنه ليس هناك وقت لإجراء المناقصة، ولا يكون عليهم رقيب إلا الله عز وجل. وهذا يعتبر من نقاط الضعف في القانون لأنه يتيح إمكانية وجود عيوب جسيمة في التعاقدات المباشرة.

١٢. ما استحدثه القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في المادة ٧٦ و ٧٩:

- القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يسمح لمجلس الوزراء بالتصريح لجهة إدارية معينة بالتعاقد بأي طريقة، سواء بطرق عادية أو مباشرة، في حالات الضرورة.

الفصل الثاني

القيود التي ترد على حرية الإدارة قبل إبرام العقد الإداري

ويقصد هنا تلك القيود التي ترد على حرية الإدارة قبل إبرام العقد، أي التي تسبق إجراءات الطرح.

القيد الأول: الاعتماد المالي

- **ماهية الاعتماد المالي:**

هو إذن بالصرف، ولكن ليس لزاماً ضرورة صرف المبلغ منه، فيمكن لها أن تلغي المنافسة أو تتريث أو تعدل عن إبرام العقد، إذا كان ذلك من دواعي المصلحة العامة.

وهو الذي يسمح لجهة الإدارة بالتعاقد، ولأجل ذلك يجب أن يتواجد قبل إبرام العقد.

- **الأثر المترتب على إبرام العقد في مخالفة الاعتماد المالي:**

استقر قضاء مجلس الدولة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، على أن العقد ينعقد صحيحاً وينتج آثاره، حتى ولو لم يوجد الاعتماد المالي، وكذلك لو خالفت الإدارة الغرض المقصود منه، أو فات الوقت المحدد لاستخدامه.

فكل هذه المخالفات لا تمس صحة العقد ولا نفاذه، بل يبقى صحيحاً، وتعوض الإدارة من يصيبه ضرر من مخالفتها، وعلة ذلك حماية للغير، ولأن الاعتماد المالي ليس بركن ولا بشرط.

ولو قلنا بغير ذلك فمن شأنه أن يزعزع الثقة بجهة الإدارة ولن يجازف أحد بالتعاقد معها، ولتعطل سير المرفق العام.

– إبرام عقد دون وجود اعتماد مالي أو تجاوزه لا يؤثر على صحة العقد وتنفيذه إلا أن ذلك لا يعفي المخطئ من المسائلة.

- **طبيعة الاعتماد المالي:**

نستخلص أنه ليس بركن ولا شرط في العقد، وأن الإدارة يقع عليها الالتزام وحدها، وتتحمل آثار عدم التزامها والمتمثل في تعويض المتعاقد معها.

ويؤاخذ تأديبياً الموظف الذي كان مسؤولاً عن ذلك الخطأ.

- **هل يمكن إجبار الجهة الإدارية على التعاقد لوجود الاعتماد المالي اللازم لذلك؟**

من المسلم به أن اعتماد المبالغ المالية من أجل تنفيذ المشاريع يكون بعد دراسات وإعداد موازنة، ولكن من المسلم به أيضاً لا يجوز من الناحية القانونية مقاضاة جهة الإدارة لعدم تعاقدها رغم وجود الاعتماد المالي، لأنه من المستقر فقهاً أن اعتماد مبالغ معينة من أجل مشروع معين، لا يعني ذلك ضرورة التعاقد على تنفيذه؛ وذلك لأن الاعتماد المالي لا يغدو إلا أن يكون إذن بالصرف، فلا يعني ذلك ضرورة صرف المبلغ المالي فيما تقرر له.

ولكن، تقاعس الجهة الإدارية في تنفيذ المشاري رغم وجود الاعتماد المالي بدون عذر أو سبب يتعلق بالمصلحة العامة، يجعل الوزير المختص مسؤولاً أمام البرلمان.

- **محظورات يتعين مراعاتها في الاعتمادات المالية:**

الفقرة الثانية من المادة (١١) على أنه: (ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة لا تجاوز السنة المالية، بشرط:

١- ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية المتتالية عما تقرر في سنة التعاقد. (حظر تجاوز الاعتماد المالي السنوي)

٢- أن يكون التعاقد في حدود التكاليف الكلية المعتمدة على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة. (حظر التعاقد بقصد استيفاء الاعتمادات المالية المقررة)

٣- حظر التعاقد في الأشهر الأخيرة في السنة المالية، إلا بشرطين: أ- ضرورة العمل، ب- موافقة السلطة المختصة.

- **الاستثناءات التي ترد على قيد الاعتماد المالي:**

أولاً: الجهات ذات الطبيعة الخاصة:

فقد أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م، لمجلس الوزراء أن يرخص للإدارة التعاقد بالاتفاق المباشر؛ لأي شخص أو جهة، في حالة تقدمه بمشروع استثماري متكامل شاملاً التمويل، وكان هذا المشروع يحقق للجهة الإدارية المتعاقد معها، الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة. ولكن هذا بعد موافقة الوزير المختص، وموافقة، وزيري، المالية، والتخطيط.

- هذا الاستثناء الأول تحدده ضوابط أربعة:

١- أن يحقق المشروع الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

٢- أن يكون الاستثناء بناء على عرض الوزير المختص، مع موافقة وزيري المالية والتخطيط.

٣- ألا يكون هناك قوانين أخرى منظمة للتعاقد.

٤- أن يصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء.

ثانياً: عقود الصفقات والمشروعات المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف:

فشرط توافر الاعتماد المالي لا يسري على التعاقدات التي تتطلب هيكلاً تمويلياً – كمشروعات البناء والتمويل، والتشغيل؛ إذا كانت هذه التعاقدات تحقق لجهة الإدارة أهدفها التنموية والاقتصادية، أو استلزمت الظروف الاجتماعية سرعة اتمامها.

– وهذا الاستثناء الثاني تحدده ضوابط ثلاثة:

١– أن يتم التعاقد وفق الأطر والشروط التي تقرها لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية.

٢– أن يضع الوزير المختص بالجهة الإدارية قواعد كل مشروع، بالاتفاق مع وزيري المالية والتخطيط.

٣– وجوب اعتماد هذه القواعد من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية.

القيد الثاني

إخطار لجنة تفضيل المنتج المصري

القاعدة:

تلتزم جهة الإدارة بإخطار لجنة التفضيل بتفضيل المنتج المصري. يجب إخطار اللجنة بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقد التي تتراوح قيمتها التقديرية بين مليون وعشرة مليون جنيه خلال خمسة أيام، وللعقود التي تزيد عن عشرة مليون جنيه تصل المدة إلى خمسة عشر يوماً. على اللجنة أن تفي بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً من تسلمها شروط ومواصفات العقد أو الطرح.

الاستثناءات

١. العقود الحكومية: إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذ قد يكون هناك وقت أمام الجهة الإدارية، وإذا لم تكن هناك مصلحة، يكون القيد موجوداً.

٢. التعاقدات من رئيس مجلس الوزراء أو بناءً على عقد من الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.

٣. التعاقدات المتعلقة بالأمن القومي: مثل شراء السلاح.

القانون المطبق للتفضيل هو رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٨.

الجهات الحكومية التي يتعين عليها تفضيل المنتج المصري:

١. الشركات المملوكة بالكامل للدولة.

٢. شركات القطاع العام.

٣. شركات قطاع الأعمال العامة.

٤. الشركات المصرية التي تملك الإدارة فيها نسبة ٥٠٪ أو أكثر.

استثناءات القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ من تطبيق أحكامه:

١. التعاقدات التي تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وهيئات المخابرات العامة.

٢. التعاقدات التي تبرمها رئاسة الجمهورية.

ملاحظات على القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥:

١. لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون ٩٠ لسنة ٢٠١٨ أن تخالف المدة التي حددها القانون. إذا كان مبلغ التعاقد من مليون إلى عشرة ملايين، يكون في خمسة أيام، وإذا زاد المبلغ عن عشرة ملايين، تمتد المدة.

٢. نص القانون ٩٠ لسنة ٢٠١٨ في المادة ١٢ على إلغاء إجراءات التعاقد في حالة مخالفة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ (تفضيل المنتج المصري). القرار يصدر من الوزير المختص، والجزاء قد يكون بإلغاء العقد نفسه. يجوز أيضاً لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية والتخطيط الإعفاء من هذا الشرط.

الأثر المترتب على مخالفة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ (تفضيل المنتج المصري):

إذا تم التعاقد مع مخالفة هذا الشرط، تكون مسؤولية الجهة المختصة أو الموظف المختص، إذ يعتبر ذلك إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة.

القيد الثالث

إعداد كراسة الشروط

قبل الإعلان عن التعاقد، تعد الجهة الإدارية كراسة الشروط والمواصفات. تتضمن الكراسة:

١. شرط الكتابة: يجب كتابة المواصفات وتعد من الشكليات.

٢. إدراج بعض الشروط: التي تفرضها دفاتر الشروط العامة التي تطبق على مجموعة من المصالح العامة ولا يجوز مخالفتها إلا بترخيص.

٣. شروط عامة معدة سابقاً: يجب على الإدارة الالتزام بالشروط العامة ويمكن الاستثناء منها ولا يجوز المخالفة إلا من السلطة المختصة.

أنواع كراسة الشروط

١. كراسة الشروط العامة: تتضمن القواعد القانونية والنصوص الحاكمة.

٢. كراسة تتضمن القواعد الفنية: تشمل الجانب الفني من الكراسة.

٣. كراسة الشروط الخاصة: تعديل الشروط الموجودة في كراسات أخرى.

كراسة الشروط بحسب القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

١. تتضمن جميع الأحكام والشروط الخاصة بالعقد الإداري.

٢. تبين طريقة التعاقد (المناقصة – المزايدة).

٣. المواصفات.

٤. مكان التنفيذ.

٥. البرنامج الزمني.

٦. مواعيد ومكان العقد.

٧. شروط الطرح.

٨. التأمينات.

٩. طرق السداد.

١٠. كيفية تقديم الشكوى.

١١. شروط الفسخ.

١٢. الجزاءات.

١٣. الالتزام بنماذج كراسة الشروط.

١٤. مدة سريان العطاء.

١٥. مراجعة كراسة الشروط من إدارة الفتوى؛ لتجنب البطلان.

القيد الرابع

الإذن بالتعاقد

تنص المادة ١١ على إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة، وتتضمن محل الطرح أو العرض، طريقة التعاقد، ومدة سريان العطاءات.

ماهية الإذن

الإذن بالتعاقد لا يعد أمراً بل يتعين على الجهة الإدارية أخذ الإذن من السلطة المختصة قبل إجراء العقد. يشبه الإذن الذي يأخذه الوصي من القضاء.

صور الإذن بالتعاقد

يلتزم المرافق العامة بالحصول على:

١. برلمان يصدر تشريعاً.

٢. موافقة السلطة المختصة (قبل التعاقد).

جزاء تخلف شرط الإذن

يعد الإذن شرطاً لصحة العقد، فإذا تخالف هذا الشرط يكون العقد قابلاً للبطلان، مما يستوجب مساءلة الشخص الذي تعاقد بدون إذن.

القيد الخامس

الاستشارات السابقة

النصوص القانونية:

تشمل المادة ٥٨ من قانون مجلس الدولة، والتي توجب أخذ استشارة قسم الرأي إذا كانت قيمة العقد أقل من ٥ آلاف، وقسم الفتوى إذا كانت أكثر من ٥ آلاف وأقل من ٥٠ ألف، والجمعية العمومية إذا كانت أكثر من ٥٠ ألف. نص القانون رقم ٩٠ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ (تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها).

وقت تدخل إدارة الفتوى

الوقت ينصب على مشروع العقد وهي استشارات سابقة على العقد، ويجب إرسالها للجهة المختصة لإدارة الفتوى قبل انعقاد العقد.

مدى التزام الجهة الإدارية بما انتهت إليه إدارة الفتوى

إدارة الفتوى غير ملزمة بمعنى أن الجهة الإدارية تتحمل المسؤولية إذا تجاهلت ملاحظات إدارة الفتوى عند التعاقد، ولا يترتب على هذا التجاهل البطلان.

حدود إدارة الفتوى

إدارة الفتوى تقوم برقابة قانونية سابقة على العقد ولا تضفي المشروعية أو عدم المشروعية عليه.

حكم مراجعة العقد بعد إبرامه

يجب إرسال العقد لمجلس الدولة قبل التعاقد. في حال إرساله بعد التعاقد لتبيين الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة، يكون ذلك لبيان تلك الأخطاء ولكن ليس للاعتماد الرسمي.

طبيعة رأي مجلس الدولة، هل هو حكم أم قرار؟

رأي مجلس الدولة لا يُعتبر حكماً لأنه لا يصدر أحكاماً، وأيضاً لا يُعتبر قراراً. إنه عمل تحضيري يعني أن العقد يكتمل عند أخذ رأي مجلس الدولة.

حالة الضرورة وعدم إرسال العقد لمجلس الدولة

هل يؤدي ذلك للبطلان؟ يجوز في حالة الضرورة عدم إرسال العقد لمجلس الدولة إذا لم يكن هناك وقت لذلك.

القيد السادس

التفويض في مجال العقود الإدارية

مفهوم التفويض

التفويض يكون للقادة الإداريين مثل المدير العام أو وكيل الوزارة. أما غير القادة الإداريين فلا يكون لهم التفويض. التفويض يجب أن يكون محدداً، فالتفويض الكامل باطل وكذلك تفويض التفويض باطل لأن التفويض في الاختصاصات الأصلية يجب أن يكون بنص.

أنواع التفويض

١. تفويض التوقيع

٢. تفويض الاختصاص

٣. التفويض بشخص

٤. التفويض بصفة

١. تفويض التوقيع: لا يشمل الاختصاص وإنما يُمارس الاختصاص صاحبه. مثال: عميد الكلية يتيح للوكيل توقيع مكانه، فالذي يمارس الاختصاص هو صاحب الاختصاص فلا ينقل الاختصاص.

٢. تفويض الاختصاص: ينقل الاختصاص من صاحبه إلى المفوض إليه.

٣. التفويض بشخص: المدير يفوض شخصاً بعينه؛ رئيس الجامعة يفوض شخصاً ويسميه.

٤. التفويض بصفة: المدير يفوض شخصاً يشغل منصباً معيناً؛ رئيس الجامعة يفوض وكيل الكلية.

انتهاء التفويض

التفويض ينتهي بانتهاء مدة التفويض. التفويض المطلق غير جائز فلا ينقل الاختصاص.

النصوص القانونية

المادة ٨١: السلطة المختصة بشغل وظائف القيادة دون غيرهم.

طرق التفويض

نوعان من القوانين ينظمان التفويض:

١. التفويض الشامل

٢. التفويض الجزئي

– التفويض الشامل: القانون الصادر سنة ١٩٤٦ ينظم التفويض ويعتبر الشريعة العامة.

– التفويض الجزئي: يتعقب القوانين المختلفة والفرعية.

الحكم في حالة التفويض الباطل:

العقد غير جائز في حالة التفويض الباطل. الفرق بين بطلان قرار التفويض والعقد؟ إذا كان التفويض باطلاً ينصرف على العقد الذي وقع فيه البطلان. بطلان القرار الإداري المنفصل لا يؤثر في العقد الإداري وقضاء الإلغاء يختص بإلغاء القرار.

قرارات لا يجوز فيها التفويض

بعض القرارات لا يجوز فيها التفويض وتكون من قبل السلطة المختصة. بعض العقود تشترط عدم التفويض وأن القرار يكون من سلطة معينة. في حالة التفويض، تُلغى كل القرارات التي تصدر من قاضي الإلغاء.

هل يجوز إنابة شخص خاص في التوقيع على العقود الإدارية؟

هناك اتجاهان:

١. رأي يقول لا يجوز. ٢. رأي يقول يجوز مثل إنابة محامي يكون مسؤولاً عن التعاقد.

الفصل الثالث

طرق التعاقد

نص القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المزايدات والمناقصات

قصر التفويض على مسائل محددة. أما القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، فقد أجاز التفويض في المناقصات العامة والمحدودة والمناقصات ذات المرحلتين.

١. حالات التعاقد بالمناقصة العامة في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨:

وضع المشرع مجالات محددة يتم فيها التعاقد بالمناقصة:

- شراء أو استئجار المنقولات والعقارات
- مقاولات الأعمال
- تلقي الخدمات
- الأعمال الفنية والاستشارية

المشرع أجاز فيها التعاقد عن طريق المناقصة العامة ويطبق هنا قانون التعاقدات الحكومية. أما القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨، فلم تشمل المناقصات المنقولات وكانت قاصرة على العقارات.

٢. حالات التعاقد بالمناقصة المحدودة:

حددت المادة ٥٧ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ حالات معينة:

١. العمليات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين، أو مقاولين، أو فنيين، أو استشاريين، أو خبراء بذاتهم.

٢. التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.

٣. توفير المستحضرات والأجهزة الطبية.

٤. إذا كان الوقت أو التكلفة لا يسمحان بطرح المناقصة.

٥. العمليات التي اتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق بشأنها.

٦. عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصة العامة.

٧. حالة التعاقد على الدراسات الاستشارية.

٣. حالة المناقصة المحلية:

قاصرة على المقاولين المحليين أو المختصين في ذات الجهة الإدارية. تكون القيمة المالية للعقد لا تزيد عن ٤ ملايين، وإذا زادت عن ٤ ملايين، نطرح طرحاً عاماً. المناقصة المحلية بين الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين، وتكون على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأجاز القانون قصر التعاقد بطريقة المناقصة المحلية فيما لا يزيد عن ٢ مليون، ويقتضي إخطار جهاز التنمية للمشروعات.

المزايدة العامة

القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ – قانون التعاقدات الحكومية

أوجب القانون أتباع إجراءات معينة في **البيع، التأجير، وشراء المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها شخصية اعتبارية،** وكذلك الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، والمنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة.

أنواع المزايدة:

أ- المزايدة العامة (وهي الأصل):

١. **المزايدة العلانية:**

- حيث يقوم ثلاثة أشخاص بالمزايدة ويمكن للجميع المشاركة.

٢. **المزايدة بالمظاريف:**

- يتم تقديم عطاء داخل مظروف مغلق. في يوم المزايدة تُفتح المظاريف ويتم اختيار العرض الأعلى بشرط أن يتجاوز الثمن الأساسي.

ب- الاستثناء:

١. **المزايدة المحدودة.**

٢. **المزايدة المحلية.**

٣. **الاتفاق المباشر.**

ملاحظات:

- **المشرع** أتاح للإدارة هذه المساحة وأقر بأنه لها الحق في إجراء البيع بالمزايدة العلانية أو غيرها. وهذا يمنح الإدارة سلطة تقديرية لاختيار الطريقة الأنسب.
- **المزايدة** تخضع للإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها، ما لم يرد نص يخالف ذلك.
- إذا كانت المزايدة داخل مصر، فيجب أن تتم بمزايدة علانية، وإذا كانت خارج مصر، يتم تطبيق قانون الدولة المعنية.
- في حالة التعذر عن البيع بالمزايدة العلانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يجب العودة لمجلس الوزراء لتحديد الشروط بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو من ينوبه.

التفرقة بين التعاقد الداخلي والخارجي

١. **إذا كانت المزايدة داخل مصر:**

- تحكمها القواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التعاقدات الحكومية ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

٢. **إذا كانت المزايدة في الخارج:**

- مثل أملاك الدولة في الخارج، يتم البيع بحسب قانون الدولة التي تُجرى فيها المزايدة.

حالات التعاقد بالمزايدة المحدودة والمزايدة المحلية

وفقًا للمادة ٧، فقرة ٢، من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، أجازت للسلطة المختصة، وبقرار مسبب منها بعد عرض على إدارة التعاقدات، إجراء التعاقد في حالات تأجير المنقولات

والعقارات والمشروعات التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية، ويجوز لها استثناءً اللجوء إلى المزايدة المحدودة أو المحلية أو الاتفاق المباشر.

١. **المزايدة المحدودة:**

- **أ** :تتحدد نطاقها في الأصناف التي يخشى عليها التلف.
- **ب** :الأصناف التي تتطلب طبيعتها ذلك، مثل الفواكه والخضروات.
- **ج** :الحالات العاجلة، إذا تعذرت المزايدة العلانية، يمكن اللجوء إلى المزايدة المحدودة.

التعاقد بالممارسة

تتحدد حالات الممارسة العامة وفقًا للمادة ٥٤، وهي الممارسة العامة، بثلاثة شروط:

١. أن يكون متاحًا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع العقد.

٢. أن تكون موضوعات التعاقد قابلة للقياس الكمي، بحيث يتم على أساسها تحديد مدى استجابة العرض الفني.

٣. أن يكون معلومًا للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات للمشاركة في العملية، لضمان تحقيق المنافسة الفعالة.

- من الواضح أن المادة ٥٤ تتحدث عن مجالات دقيقة وخاضعة للقياس الكمي مع توفر عدد من الموردين أو المتنافسين.

التعاقد بالممارسة المحدودة

أجازت المادة ٥٥ التعاقد بطريقة الممارسة المحدودة في الحالات التالية:

١. الأصناف التي يتم تصنيفها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها، مثل الأصناف اليابانية أو تلك التي تتطلب طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.

٢. التعاقدات المتعلقة بالأمن القومي.

٣. الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليًا بسبب عدم وجود بدائل لها، وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر.

الاستثناءات التي ترد على طرق التعاقد المحددة

الحالة الأولى: إبرام اتفاقية إطارية

- يتم وضع شروط عامة ويأتي شخص أو اثنين لشراء السلع الخاصة بي لأنه لا يوجد مثلها في الخارج. هذه الحالة تُسمى طريقة التعاقدات المحدودة.

- عند إبرام اتفاقية إطارية، يخرج الأمر عن نطاق البيع والشراء الذي يتم بالمناقصة أو المزايدة، لأن الاتفاقية الإطارية تكون اتفاقًا مع جهة من الجهات. وهذا يمثل خروجًا عن القاعدة الأصلية التي تقضي بأنه إذا اخترت طريقة معينة، فلا بد من الالتزام بها ولا يجوز التحول إلى طريقة أخرى.

- في حالة الاتفاقية الإطارية، يجوز اللجوء إلى الأسلوبين معًا.

المادة ٦٥ من قانون التعاقدات الحكومية

نص المادة ٦٥ :يجوز للجهة الإدارية طرح احتياجاتها أو احتياجات جهة إدارية أخرى أو أكثر باتباع طريقة المناقصة أو المزايدة بما يتفق مع طبيعة العملية محل الطرح، وإبرام اتفاق إطاري بذلك. يشمل هذا الاتفاق القواعد والشروط التي سيتم من خلالها إصدار أوامر توريد أو الإسناد، وذلك في الحالات التالية:

١. **الحاجة للتعاقد المتكرر:**

- على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال والخدمات أو تقديم الخدمات الاستشارية. بمعنى أنه إذا كنت تحتاج إلى سلعة معينة بصفة متكررة، فلا يتعين إجراء مزايدة في كل مرة، بل يمكن الاستفادة من المزايدة العلانية والمزايدة المحدودة.

٢. **توقع الجهة الإدارية:**

- وفقاً للمجرى العادي للأمور، وبسبب طبيعة الأصناف، أو الأعمال، أو الخدمات، أو الدراسات الاستشارية المطلوبة. بمعنى أن الجهة التي تستخدم هذه الطريقة يجب أن تكون على دراية بالأمور العادية وليست الاستثنائية، وأن تحدد الجهة الإدارية وفقاً للمجرى العادي للأمور سبب طبيعة الصنف، دون معرفة دقيقة بالتوقيت، أو التوريد، أو التنفيذ، أو الكمية. إذا كانت هذه الأمور محددة مسبقاً، فلا يجوز اللجوء لوسيلة استثنائية.

٣. **الحالات الأخرى:**

- التي ترى الجهة الإدارية أنها مناسبة لاتخاذ هذا الأسلوب من التعاقدات، بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات أو تنميط الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة.

ملاحظات:

- يتيح القانون للجهة الإدارية تحديد مجالاتها في الاتفاقية الإطارية. الاتفاقية الإطارية هي اتفاقية عامة تحتوي على كثير من الطرق، وتتعلق بمجالات متكررة تتسم بالعمومية أو التي تتوقع الجهة الإدارية الحاجة إليها عاجلاً في المستقبل.

- خول المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية في اتباع أي طريقة من الطرق إذا رأت أن الأسلوب المناسب لها في مجالات التعاقد.

- اشترط القانون في المادة ٦٥ أن تتضمن شروط الطرح والمواصفات الفنية والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ومعدلات الاستهلاك التاريخية والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو إطارات الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية بحسب الأحوال.

الحالة الثانية: التعاقد بالمسابقة للحصول على عمل ابتكاري

أجاز القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للجهة الإدارية عدم التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون، وأن تعلن عن مسابقة للحصول على عمل ابتكاري. بمعنى أننا نقوم بالإعلان عن مكافحة وباء معين، فهذه تُعتبر مسابقة لعمل ابتكاري.

- يكون الإعلان عن المسابقة في إحدى الصحف القومية واسعة الانتشار، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات الحكومية.

إلغاء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات

الإلغاء الوجوبي

أولاً: حالات الإلغاء الوجوبي في المناقصة أو الممارسة:

١. إذا استُغني عنها نهائيًا.

٢. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣. إذا تبين وجود احتكار، أو تواطؤ، أو احتيال، أو فساد بين مقدمي العطاء.

٤. إذا تبين وجود خطأ أو نقص في كراسة الشروط والمواصفات.

ثانياً: حالات الإلغاء الوجوبي للمزايدة:

١. إذا استُغني عنها نهائيًا.

٢. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣. إذا لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية.

٤. إذا تبين وجود احتكار أو تواطؤ أو احتيال أو فساد بين المتزايدين.

الإلغاء الجوازي

حالات الإلغاء الجوازي:

١. إذا لم يُقدم سوى عطاء وحيد مستوفٍ للشروط (مناقصة، مزايدة، ممارسة).

٢. إذا لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد، ولم تكن الحاجة تسمح بإعادة الطرح بشرط أن يكون العطاء مناسبًا من الناحية الفنية وللقيمة التقديرية (مناقصة، ممارسة).

٣. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تتجاوز القيمة التقديرية (مناقصة، ممارسة).

٤. إذا اقترنت العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات.

الآثار المترتبة على إلغاء التعاقد

١. يجب أن يكون القرار الإداري مُسببًا.

٢. يجب أن يكون القرار الإداري صادرًا من السلطة المختصة.

٣. يجب أن ترد قيمة كراسة الشروط والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات، ما عدا التي تم الإلغاء فيها بسبب وجود تواطؤ أو احتكار أو احتيال بينهم.

الطبيعة القانونية للإلغاء

تعد هذه القرارات منفصلة سواء كانت سابقة على إبرام العقد أو في مرحلة إبرام العقد، وبالتالي يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء.

التعاقد بطريق الاتفاق المباشر

كان القانون القديم يقصر طرق التعاقد على المزايدة والمناقصة فقط، وكان التعاقد بالاتفاق المباشر يكون في أضيق نطاق وبشروط محددة. إلا أن المشرع قد توسع في القانون الجديد في طريق الاتفاق المباشر على الرغم من كونه استثناء.

الحالات التي يجوز فيها التعاقد بطريق الاتفاق المباشر:

١. الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن من الممكن التوقع بها.

٢. وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد.

٣. تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد سوى مصدر واحد.

٤. عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الضرورة تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.

٥. الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح بإجراءات المناقصة أو الممارسة.

٦. في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.

٧. الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر.

٨. الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف، أو تنفيذ الأعمال، أو الخدمات، أو تقديم الدراسات الاستشارية.

٩. توقع الجهة الإدارية وفقًا لمجري الأمور العادية بسبب طبيعة الأصناف.

١٠. الحالات الأخرى التي ترى الجهة الإدارية مناسبة اتباع هذا النمط من التعاقد.

• في هذه الحالات يجوز التعاقد بأي طريقة ولا تلتزم الجهة الإدارية باتباع طريق معين.

١١. التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات الأساسية التي تمتلك في الدولة حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية مجلس الإدارة.

١٢. أجاز القانون لمجلس الوزراء التعاقد بالطريق المباشر في غير حالات الضرورة.

١٣. أجاز القانون لوزارتي الدفاع والداخلية وأجهزتهما التعاقد بالطريق المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.

١٤.يجوز للجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التعاقد بالطريق المباشر بموافقة السلطة المختصة.

- حظر القانون التفويض في الاختصاصات، بينما أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد المباشر فيما يجاوز اختصاص الوزير أو المحافظ.

تم بحمد الله

مع كامل الاحترام والتقدير

للدكتور فؤاد النادي

إعداد/ حازم مكي

كتابة/ عبد الرحمن محمد

مراجعة شكلية/ عمر محمد – حورس

لا تنسونا في صالح دعائكم